

1511738-08.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... é utilizada para a tipificação do furto qualificado e as demais, para a dosimetria da pena, alterei o meu posicionamento anterior e passei a adotar tal entendimento.

Desta forma já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511738-08.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511738-08.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE AUGUSTO SANTANA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

FELIPE AUGUSTO SANTANA (RG 26333576/SP) e SANDRO APOLINARIO DA SILVA (RG:203484422-89) foram denunciados como incurso no artigo 155 § 1º e 4º, inciso II e IV, c.c. artigo 61, II, alínea j, todos do Código Penal porque consta no inquérito policial que no dia 30 de maio de 2020, por volta das 22h12min, na Rua Dona Ana Araújo de Paula, 500, Água Rasa, nesta cidade e comarca da capital, teriam subtraído, previamente ajustados e com unidade de propósitos, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, fios de eletricidade, avaliados em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente à vítima Jeronimo da Fonseca Cardoso.

Os réus foram presos em flagrante (fls. 4), sendo que o acusado FELIPE teve a sua prisão convertida em preventiva e o corréu Sandro foi posto em liberdade (fls. 109/111) por determinação do Juízo de Plantão (fls. 78/81). Em seguida, foi concedido o benefício da liberdade provisória ao corréu FELIPE (fls. 116/117). A denúncia foi recebida (fls. 116/118). O corréu FELIPE foi citado (fls. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 148/149). A decisão a fls. 151 manteve o

recebimento da denúncia.

O corréu SANDRO foi citado por edital e, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional. Durante a primeira audiência de instrução foi determinado o desmembramento em relação ao corréu SANDRO. Em seguida foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial.

Durante a audiência em continuação foi ouvida a outra testemunha policial e, ao final, o réu FELIPE foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, além de uma das circunstâncias qualificadoras servir como circunstância judicial desfavorável nessa fase, e a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da tentativa e redução da pena no máximo legal; o afastamento da agravante da calamidade; a substituição nos termos do artigo 44, § 3º do CP por não se tratar de reincidente específico; a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena; e por fim, a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 10/12); autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/15); auto de avaliação (fl. 16); laudos no objeto apreendido e no local dos fatos (fls. 137/140 e 261/270); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Jeronimo da Fonseca Cardoso afirmou em sede policial que no local funcionava uma empresa de móveis para escritório, que está desativada há 02 anos. Informou que, naquela noite, policiais militares relataram terem indivíduos arrombado portão e grade, subtraindo cabos de alta tensão de energia, os quais foram apreendidos e devolvidos.

Em juízo, a vítima declarou que foi avisado à noite e quando chegou ao local, quase duas horas depois, todos já tinham ido embora. Informou que o imóvel era dos seus filhos, que estavam viajando. Disse que foi levado a fiação do poste da parte da frente. Declarou que o portão foi aberto, mas não se lembra como, e a caixa de entrada do poste, onde ficavam os fios, foi arrombada. Aduziu que, na delegacia foi devolvida a fiação, e que ficou de 5 a 6 mil reais para consertar o estrago. Disse que não teve contato com os réus. Informou que o estabelecimento estava fechado há um ano e meio aproximadamente, e havia alguns dias que tinha ido ao local, onde não havia nada de anormal. Falou que, quando chegou ao local, os policiais ainda estavam lá, somente os réus que já tinham sido levados, e nem na delegacia estavam mais.

As testemunhas policiais militares Kaue Messias e Everton Jose Garcia afirmaram em sede policial que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram solicitados via "COPOM" para atender a ocorrência de furto em andamento em uma indústria. Narraram que se dirigiram para a Rua Dona Ana Araújo de Paula e próximo ao numeral 610 e da esquina com a Avenida Vila Ema, avistaram dois indivíduos caminhando pela via. Relatam ter o acusado "Felipe" carregado um alicate grande e com o indivíduo de prenome "Sandro", um saco contendo fios grossos de alta tensão de eletricidade, os quais disseram que haviam furtado de uma empresa estabelecida naquela rua no numeral 520. Contam que se dirigiram à referida indústria onde constataram que o portão e uma grade haviam sido arrombados e os fios da caixa de energia cortados. Em juízo, o policial Kaue narrou que estavam em patrulhamento quando foi avisado sobre um furto a um estabelecimento comercial em andamento e, ao chegar à via informada, encontraram dois indivíduos perto ao local, um portando fios de eletricidade, em grande quantidade, e o outro, um alicate de corte. Aduziu que havia um prédio residencial bem perto do estabelecimento comercial, onde moradores indicaram que os indivíduos abordados estavam no prédio comercial. Informou que os abordados confessaram que haviam furtado os fios no estabelecimento comercial, que estava há aproximadamente 50 metros do local da abordagem. Disse que fez uma varredura no local e constatou que os indivíduos chegaram a entrar na parte interna, mas nada foi subtraído, e também que a caixa de luz, de onde foi furtado o

fio, foi arrombada (grade, cadeado e porta). Informou que os fios cortados condiziam com os fios que os réus estavam portando, e que estes admitiram que tinham furtado. Afirmou que não conhecia os detidos, que não se lembra se o réu portava os fios ou o alicate, e também não se recorda do réu como um dos detidos. Em juízo, o policial Everton narrou que foi irradiado via Copom, então se deslocaram até o local e abordaram os indivíduos, um com a ferramenta e o outro com o objeto do furto, que eram fios de cobre industriais. Disse que indagaram os indivíduos e eles admitiram que tinham entrado numa indústria e tinham furtado. Explicou que a caixa de força estava rompida, com sinais de arrombamento. Perguntado quais eram os sinais, respondeu que era um portão e uma grade. Informou que ambos foram abordados na via, não se lembra a que distância do local dos fatos, e estavam quase virando a rua, pelo que se recorda, já que faz um bom tempo. Respondeu que não lembra o que o réu trazia consigo, e que este está bem diferente da época. Aduziu que não chegou a ver ninguém mexendo na caixa de força. Destacou que dentro do saco havia fios, alicates, se não se engana, um alicate grande, e, salvo engano, os fios estavam com SANDRO, enquanto o alicate estava com FELIPE. Os réus, em seus interrogatórios policiais, confessaram que estavam “roubando” os objetos em questão.

Em juízo, o corréu FELIPE disse que estava em situação de rua desde 2012 e fazia reciclar, então saiu com uma carroça, parou numa esquina para pegar latinha, momento em que viu várias viaturas passando, e uma delas parou, o abordou e perguntou se o réu tinha passagem. Alegou que, com a resposta positiva que ele deu, o levaram até o local dos fatos, onde já tinha um rapaz algemado, que ele não conhecia, e havia uma sacola ao lado. Informou que não estava muito longe do local dos fatos.

Diante das provas orais colhidas, não restam dúvidas sobre a autoria dos fatos imputados ao acusado.

Narram os policiais que, informados sobre uma ocorrência de furto em andamento, se deslocaram até o local e surpreenderam ambos os acusados com a res furtiva e com a ferramenta utilizada para a prática do crime próximo ao estabelecimento onde o crime tinha sido cometido.

É indiferente quem carregava os fios subtraídos e quem carregava o alicate usado no crime, já que ambos atuaram com unidade de propósitos e para proveito comum.

Além disso, em que pese a negativa em juízo, o próprio acusado confessou o crime informalmente e também na delegacia.

Comprovada a autoria, resta a análise das qualificadoras.

O concurso de pessoas está presente, uma vez que duas pessoas agiram em unidade de propósitos e conforme ajustamento prévio.

No mesmo sentido, o reconhecimento do cometimento do delito mediante o arrombamento do portão e da grade e do gradil de vedação do quadro de energia, conforme constatado no laudo pericial de fls. 261/270. Destaca-se que o alicate-vergalhão que foi utilizado para o rompimento dos obstáculos, foi apreendido (fls. 13/14) e periciado (fls. 137/140).

Entretanto, embora comprovado que a ocorrência tenha ocorrido à noite, conforme demonstrado no boletim de ocorrência, deixo de reconhecer a causa de aumento pela prática do crime durante o repouso noturno, respeitando-se novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento recente (Tema Repetitivo 1087), fixou a tese de que a causa de aumento previsto no art. 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (4º).

Assim, de rigor a condenação do réu, nos termos acima.

Passa-se à aplicação da pena.

Na primeira fase, acompanhando a jurisprudência majoritária das Cortes Superiores, segundo a qual, na presença de duas ou mais qualificadoras, a primeira é utilizada para a tipificação do furto qualificado e as demais, para a dosimetria da pena, alterei o meu posicionamento anterior e passei a adotar tal entendimento.

Desta forma já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE

AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145000 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, Processo Eletrônico DJe-073, Divulg. 16-04-2018, Public. 17-04-2018)

Assim, fixo a pena-base para o crime de furto qualificado acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, utilizando-se uma das qualificadoras para sua exasperação, além de o réu possuir maus antecedentes. Na segunda fase da pena, considerando-se que o réu é reincidente (fls. 49/64), incide aumento na fração de 1/6. Tendo-se em vista que foi considerada a confissão informal e extrajudicial do acusado na fundamentação de sua condenação, utilizo-a também nesta fase, favoravelmente ao réu. Assim, fica compensada a agravante da reincidência, nos termos do artigo 65, alínea d, do Código Penal.

Ainda na segunda fase, cabe mencionar que a agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a

prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavírus disease 19 - COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular para os réus.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena para ambos. Então, a pena definitiva será de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, lido a contrario sensu, ante a sua reincidência. Por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3º, CP) e ante a quantidade de pena aplicada, viável a substituição da pena por restritivas de direitos, já que o réu não é reincidente específico.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu FELIPE AUGUSTO SANTANA (RG: 26333576/SP) como incurso no artigo 155 § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de reclusão e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. Ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas e o réu respondeu ao processo em liberdade, e nessa situação deverá permanecer.

Fica autorizada a destruição do alicate apreendido com o réu.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA